

1500086-78.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...). II - Consolidou-se o entendimento desta Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500086-78.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500086-78.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2007248/2022 - 04º D.P. AMERICANA, 22344657 - 04º D.P. AMERICANA, 81/22/350 - 04º D.P. AMERICANA, 2007248 - 04º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANI APARECIDO DA ROSA VICENTIN e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

GIOVANI APARECIDO DA ROSA VICENTIN e GILVOMAR DUARTE, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal, porque na data e local descritos na denúncia, previamente ajustados e em unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, contra a vítima G.G.C., subtraíram para o proveito comum, coisas alheias móveis, ou seja, uma carteira com documentos pessoais, um maço de cigarros, um rádio HT marca "BAOFENG", um aparelho de telefone celular marca "SAMSUNG" e uma caneta própria para registrar ronda.

A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2022 (fls. 115/116).

Os réus foram citados, apresentando defesa (fls. 139/141).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e os réus foram interrogados (fls. 164/165 e 181/182).

Em seus memoriais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 186/188), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação dos réus.

Ao manifestar-se, o Doutor Defensor dos réus (fls. 191/194) requereu desclassificação, tendo em vista a inexistência de arma de fogo, além da aplicação da atenuante da confissão, com pena mínima e regime mais brando.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima.

A doutrina distingue duas espécies de roubo: roubo próprio, no qual a violência ou a grave ameaça é exercida antes da subtração da coisa, ou seja, a violência ou grave ameaça é exercida para que o agente subtraia a coisa material e ainda o roubo impróprio, quando o agente emprega a violência contra a pessoa ou a grave ameaça logo após subtraída a coisa.

O roubo próprio se encontra capitulado no "caput" do artigo 157 do Código Penal, e o roubo impróprio se encontra capitulado no parágrafo 1º do mesmo artigo.

Sobre o momento da consumação do delito de roubo, decidiu a 9ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com voto magistralmente relatado pelo eminente Desembargador Souza Nery, que este se dá no exato ponto em que, exercida eficazmente a violência (lato sensu), o agente consegue retirar a coisa da esfera de controle imediato do sujeito passivo, estando portanto já consubstanciados todos os elementos da definição legal de roubo, independentemente do que venha a ocorrer na seqüência, ou seja, do grau de impertubabilidade da posse da res, da existência ou não de perseguição ou de sua intensidade, etc. (Apelação Criminal 990.09.067051-7, j. 13.08.2009).

Nesse sentido, o entendimento do STF:

"... o roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso Direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência da posse. E a perseguição - não fosse a legitimidade do esforço imediato - seria ato de turbacão (ameaça) à posse do ladrão." (RE nº 102.490-9/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, in RT 677/428).

A materialidade do delito de roubo se encontra comprovada pelos autos de fls. 07/09 e 10/16.

A autoria é indubitosa.

Os réus foram presos em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Em poder dos acusados foram encontrados os bens subtraídos. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175). Erich).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita dos bens. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. Vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, podendo o magistrado valer-se de todo o acervo probatório para decidir, desde que o faça motivadamente. A perícia não é o único elemento de prova apta para demonstrar o emprego da arma e a impossibilidade de sua realização, para comprovação da potencialidade lesiva do artefato, não tem o condão de, por si só, afastar a majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal..." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse

de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO - roubo - ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça posse mansa, pacífica e desvigiada - desnecessidade - precedentes das Cortes Superiores caso concreto onde não houve perseguição, sendo o réu detido por policiais em patrulhamento existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea reconhecimento da forma tentada impossibilidade. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

Roubo - Objetos subtraídos encontrados em poder do agente - Ônus de demonstrar a legitimidade da posse transferido a defesa - Inteligência do art. 156 do CPP. 131 - Segundo o art. 156 do CPP, a apreensão da res furtiva em poder do agente enseja inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente versão acusatória de tal circunstância. RJDTACRIM VOL.6 PÁG. 140 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-NOGUEIRA FILHO.

Ouvido em juízo, o réu Giovani confirmou parcialmente a prática do delito. Alegou que teve uma recaída nas drogas, quando o Gilvomar o convidou para "fazer uma fita/corre", e adentraram a firma. Disse que Gilvomar rendeu o segurança e pegou os pertences, enquanto estava por perto. Nega que estivessem com arma de fogo, possuindo apenas um alicate, sendo que Gilvomar portava a réplica. Por fim, o primo de Gilvomar estava junto, mas não sabe seu nome.

E, ouvido em juízo, o réu Gilvomar confirmou parcialmente a prática do delito. Alegou que estava devendo para o traficante, e chamou o Giovani para a prática do delito. Negou a existência de arma de fogo, sendo apenas a réplica apreendida.

Em audiência, a testemunha/vítima, relatou o ocorrido.

A vítima Gilson reforçou suas declarações ao informar que estava realizando a ronda na empresa, e verificou indivíduos no local, quando foi abordado, sendo que um deles, o mais magro, portava um revolver, e o outro, mais baixo, uma réplica de metralhadora. Disse, ainda, que foi ameaçado, e teve os objetos subtraídos. Os réus ordenaram que deitasse no chão, e após saíram correndo. Narrou que tentou seguir o caminho dos réus, tendo encontrado a polícia e noticiado o ocorrido. Informou que pouco após, a polícia confirmou a apreensão dos réus, e recuperou parte dos bens, além da réplica de arma de fogo. Por fim, reconheceu os réus, sendo que era Giovani quem tinha a posse da arma de fogo, e Gilvomar o simulacro.

Não há nos autos prova de que a vítima/testemunha conhecia os réus anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-los, atribuindo-lhes falsamente a prática de crime.

Os Guardas Municipais informaram que estavam em patrulhamento quando foram acionados em razão de um possível furto, com as características dos indivíduos. No local, durante as buscas, conseguiram abordar Gilvomar, dentro da área da mata, sendo que Giovani empreendeu fuga pela rodovia, mas também foi abordado. Após, tomaram conhecimento de que, na verdade, tratava-se de um roubo, sendo que na mochila, localizaram parte dos pertences subtraídos. Em diligência na empresa, localizaram o simulacro de arma de fogo, e o vigilante informou que eles portavam também um revolver, calibre 38, mas não foi encontrado. O vigilante informou, também, que dois indivíduos pularam o muro e, portando as armas, levaram os objetos. Indagados, os réus não negaram o delito, alegando uso de drogas. Por fim, a vítima reconheceu os bens encontrados e os réus.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

"Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas ("Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

As provas colhidas são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória.

Preliminarmente, a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, letra "d" do Código Penal não pode ser aplicada no caso em tela, posto que os réus proporcionaram uma versão parcial e qualificada (com alegação de causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade), na tentativa de excluir a qualificadora da arma de fogo.

(...) o agente que confessa a autoria, quando já desenvolvidas todas as diligências e existindo fortes indícios, ao final confirmados, não faz jus à atenuante. Para a incidência desta, é necessária a admissão da autoria, quando esta ainda não era conhecida (...)." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. v. 1. p. 494).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...). II - Consolidou-se o entendimento desta Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a confissão do réu, ainda que qualificada, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Esse entendimento, inclusive, foi recentemente sumulado, consoante dispõe o enunciado n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." III - Na hipótese, não há qualquer dado que justifique a redução da reprimenda imposta em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que as declarações do paciente não foram em nenhum momento levadas em consideração para fundamentar a condenação que lhe foi imposta. IV - (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 432.165/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 29/05/2018)

Apelação da Defesa - Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo - Ação delitiva captada pela câmera de segurança - Admissão do réu quanto ao furto - Negativa a respeito do rompimento de obstáculo - Ambas qualificadoras comprovadas pela prova técnica - Consistentes depoimentos da testemunha e do policial civil -

Aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade - Conduta que não pode ser considerada irrelevante - Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desprezo pelo patrimônio alheio - Acusado envolvido em outro delito de furto no mesmo local, contando ainda com uma condenação em primeira instância, obstando o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade - Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal ante a presença da segunda qualificadora - Impossibilidade de incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, pois parcial - Regime inicial aberto mantido, assim como as penas alternativas - Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0002340-50.2015.8.26.0111; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. Autoria e materialidade comprovadas. Tentativa. Não ocorrência. Penas mantidas. Atenuante da confissão não reconhecida, porque o acusado não admitiu a comparsaria. Regime prisional semiaberto mantido, pelos maus antecedentes e reincidência de um dos agentes. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 0000224-56.2017.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)

Em que pese a defesa apresentada, não é possível a absolvição dos réus, ou a exclusão da qualificadora referente ao uso de arma de fogo. Assim, considerando a ameaça efetuada em concurso pelos réus, inclusive com utilização de arma de fogo, ao procederem a subtração dos bens, restou configurado o roubo qualificado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA EM CONCURSO FORMAL. Condenação mantida. Réus confessos. Palavras do ofendido e de testemunha presencial. Desclassificação para furto afastada. Grave ameaça comprovada pela simulação do porte de arma. Crime consumado. Inversão da posse. STJ, Súmula nº 582. Penas mantidas. Maus antecedentes comprovados. Concurso formal caracterizado. Regime prisional fechado. Impossibilidade de substituição da pena. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500056-43.2018.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 02/09/2019)

Pela mesma razão, não há que se falar em menor importância das ações, posto que o agente que contribui ativamente para a realização do crime, não podendo ter sua conduta classificada como de menor importância.

Apelação criminal. Roubo. Concurso de agentes. Autoria. Participação. Menor importância. É de autoria concursiva, e não de simples participação ? menos ainda e menor importância ? a conduta da pessoa que executa, em conjunto com as demais, o núcleo típico consistente em subtrair a coisa da vítima, ainda que não a rendendo frontalmente. (TJSP; Apelação Criminal 0054873-04.2017.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 06/11/2018)

Ainda, não é possível o reconhecimento da desclassificação do delito, considerando a violência e ameaça perpetradas, em concurso de pessoas e com utilização de arma de fogo.

ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE. Se a vítima declara, de forma firme e segura de que sofreu grave ameaça, correta a imputação pelo crime de roubo. COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA IMPASSÍVEL DE ABRANDAMENTO - REGIEM PRISIONAL ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500638-48.2019.8.26.0533; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES E SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - Não cabimento: Bem demonstrada a abordagem efetuada por três indivíduos que, simulando o porte de armas, arrancaram a bolsa do braço da vítima e, portanto, presentes a grave ameaça e violência, impossível falar-se em desclassificação. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0007125-34.2009.8.26.0477; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/08/2010; Data de Registro: 09/09/2010)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA EM CONCURSO FORMAL. Condenação mantida. Réus confessos. Palavras do ofendido e de testemunha presencial. Desclassificação para furto afastada. Grave ameaça comprovada pela simulação do porte de arma. Crime consumado. Inversão da posse. STJ, Súmula nº 582. Penas mantidas. Maus antecedentes comprovados. Concurso formal caracterizado. Regime prisional fechado. Impossibilidade de substituição da pena. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500056-43.2018.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 02/09/2019)

Relativo à qualificação (art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP), provada pelas testemunhas a existência da arma de fogo, não pode a qualificadora ser afastada pela simples falta de sua apreensão em poder dos réus. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO. Recursos defensivos. Roubos majorados pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, além de corrupção de menores, praticados em concurso formal e material. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Defesa que não se insurgiu contra o encerramento da instrução criminal no momento oportuno. Preliminar afastada. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria dos delitos. Crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90. Delito formal. Comprovado o envolvimento de adolescente nas infrações penais praticadas pelos réus. Pretensão de afastamento da majorante decorrente do uso de arma de fogo. Apreensão e perícia da arma que não são indispensáveis para a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Uso da arma de fogo comprovado pelas declarações das vítimas. Arma de fogo que possui potencial lesivo inerente à sua natureza. Condenação mantida. Dosimetria penal. Viável a redução da pena-base relativa ao corréu Leandro. Cabível o reconhecimento da continuidade delitiva específica entre os crimes de roubo. Aumento decorrente do concurso formal por violação a patrimônios jurídicos distintos afastado, a fim de evitar bis in idem. Precedentes do STJ. Penas redimensionadas. Regime inicial fechado mantido em razão do quantum das penas e da gravidade concreta dos delitos. Recursos parcialmente providos (TJSP - Apelação Criminal 0000982-34.2018.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)

APELAÇÃO. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da causa de aumento. Prova técnica substituída pela oral. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Reconhecimento de duas causas de aumento, uma das quais foi considerada como circunstância judicial. Alegação de imposição de dois aumentos sucessivos. Dosimetria mais benéfica. Ausência de modificação da quantidade de pena. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP - Apelação Criminal 1500108-23.2018.8.26.0616; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Apelação. Roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo em concurso formal. Sentença condenatória. Recursos das defesas. Materialidade

e autoria demonstradas. Reconhecimento pessoal dos acusados. Relatos dos investigadores de polícia. Emprego de arma demonstrado. Desnecessidade de apreensão e perícia. Prova oral que indica a presença da causa de aumento. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias e consequências do delito. Roubo ocorrido em estabelecimento comercial com pluralidade de vítimas e bens subtraídos. Reconhecimento do concurso formal. Bis in idem configurado. Regime fechado mantido. Manutenção da custódia cautelar. Recurso provido para readequar as penas impostas. (TJSP - Apelação Criminal 1502946-56.2018.8.26.0577; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

ROUBO - Emprego de arma - Ausência de apreensão - Testemunho da vítima - Suficiência - Qualificadora - Configuração.74b - O testemunho da vítima é suficiente para comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão. RJDTACRIM VOLUME 10 ABRIL/JUNHO 1991 PÁGINA:142 RELATOR:-MARREY NETO

Desta forma, restou comprovado nos autos que os réus agindo em concurso, e mediante grave ameaça, exercida com a posse de uma arma de fogo, subtraíram os objetos delimitados na exordial, para o proveito comum dos envolvidos.

Portanto, não há que se falar em qualquer absolvição ou desclassificação, restando configurado o roubo qualificado tanto pelo concurso de pessoas, quanto pela utilização de arma de fogo.

Assim sendo, a condenação dos acusados é medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

Relativo a Giovani, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

O réu Gilvomar é portador de péssimos antecedentes (fls. 68/72), o que impõe a majoração da pena base como circunstância judicial. Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto) fixando-a em quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa para o delito de roubo.

Na segunda fase, anoto que o réu Gilvomar é também reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 68/81, razão pela qual aumento a pena em 1/6, perfazendo cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e doze dias-multa, para o roubo.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumprir precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são

utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Ainda, conhecidas as causas de aumento, ensejando o roubo qualificado, por força do que dispõe o § 2º, inciso II, e do §2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal (concurso de agentes e arma de fogo), e no termos do § único, do art. 68, do CP, excepcionalmente, neste caso, tendo em vista a ausência circunstâncias concretas a fundamentar a opção mais gravosa (duplo acréscimo 1/3 e 2/3), acresço as penas em apenas 2/3 (dois terços), fixando a pena base em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para Gilvomar. E, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, para Giovani.

Verifica-se a ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

O dia-multa é fixado no piso.

Regime de cumprimento da pena.

Superada a fixação da pena, com os fundamentos legais já expostos, de rigor a estipulação do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, como exigido pelo artigo 59, inciso III do Código Penal.

Além da gravidade, só por si, o crime, que está num crescente assustador, colocando em polvorosa a comunidade ordeira de Americana, suas seqüelas para as vítimas, que prestaram depoimento na ausência dos réus, certamente atemorizadas ainda pelos fatos. A própria legislação atual, considerando a violência e a grave ameaça embutida no tipo, veda a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Além disso, o réu Gilvomar é reincidente e Giovani possui processos em andamento, além de não provarem desenvolver qualquer atividade lícita.

Não é por outro motivo que o extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, na maioria de suas Câmaras e distinguindo corretamente as exigências para a fixação da pena e de regime, vinha elegendo o fechado como regra em se tratando de crime de roubo. Nestes autos, volto a anotar, circunstância alguma recomenda fixação de regime mais brando.

Assim o entendimento da doutrina:

"...pacífica a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois se deve levar em conta as circunstâncias do delito, que, no caso, vêm causando grande comoção social (MIRABETE, Julio Fabbrini, Execução Penal, 8a ed., Atlas, 1997, p. 255, texto e nota 6)".

"Não se pode porém olvidar que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-seá com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, consoante dispõe seu art. 33, § 3º.

Desse modo, num roubo, com emprego de arma, cometido por réu primário, ainda que a pena concreta não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, o juiz poderá determinar o cumprimento da pena em regime fechado. (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", Ed. Oliveira Mendes-APAMAGIS, 1997, p. 8)

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A

8. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. "É cabível o regime fechado ao condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33 do Código Penal, ainda que reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis" (HC 314.296/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1712438/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018)

ROUBO MAJORADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, mediante concurso de agentes, de rigor a manutenção do édito condenatório. REGIME PRISIONAL - CRIME GRAVE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - CONVENIÊNCIA DO REGIME INICIAL FECHADO. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e da primariedade do réu. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1530412-93.2018.8.26.0037; Relator: Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/04/2020; Data de Registro: 02/04/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a escolha do sistema prisional não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum de pena firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso concreto. 2. Com efeito, não é possível constatar flagrante ilegalidade na imposição do regime inicial fechado ao paciente, pois, embora a sua pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável, a exemplo dos maus antecedentes, indica que o modo mais gravoso de execução mostra-se adequado na espécie. [...] 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 326.343/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 25/11/2015)

ROUBO - Regime Prisional Fechado - Necessidade Indeclinável - "É de primeira evidência que a perpetração de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que regem a convivência social. Pelo que, deve o Juiz sujeitar quem o pratica ao mais severo regime prisional. Demais, não é lícito dar de mão à circunstância de que a lei presume a periculosidade do condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, haja vista que subordina a concessão do livramento condicional a exame criminológico elidente, scilicet, atestatório da cessação da potencialidade recidivista" (TACRIM_SP - Ap. nº 1.004.065/3 - São Paulo - 7ª Cam. - Rel. Juiz CORRÊA DE MORAES, j. 13.3.97, v.u.)

REGIME PRISIONAL - Fechado - Substituição pelo regime semiberto - Réu primário - Inadmissibilidade - Determinação do regime inicial que se faz com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal - Hipótese em que o crime de roubo evidencia a periculosidade do agente - Sentença confirmada - Recurso não provido. (Relator: Nelson Fonseca - Apelação Criminal n. 167.440-3 - São Paulo - 15.09.94)

A esse respeito, julgando recurso deste juízo, o Eminentíssimo Magistrado Corrêa de Moraes, com muita propriedade assevera que a fixação de outro regime que não o fechado nos casos de roubo qualificado significa não apenas abrir uma porta para a impunidade, mas rasgar a via larga da impunidade, e chega a afirmar que a fixação de outro regime é crime de lesa-sociedade. Cumpre, pela pertinência, transcrever o V. Acórdão, brilhantemente relatado:

"Em se tratando de roubo, crime cuja execução revela personalidade marcadamente perigosa, fechado é o único regime ajustável ao princípio da necessidade e suficiência (C.P., art. 59).

Esta Colenda Câmara tem proclamado, vezes sem conta, que o regime fechado é o único compatível com o início do cumprimento de pena imposta ao autor de roubo, uma das mais intranquilizadoras expressões da criminalidade, nos tempos correntes.

Vem de molde observar que inexistente relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e a determinação do regime prisional, seguro que esta será feita com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal (cf. § 3º do art. 33).

Sobre o tema, cabe invocar o seguinte ensinamento do STF:

"A determinação do regime inicial de cumprimento de pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Código Penal, mas, também de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59"(HABEAS-CORPUS nº 70.289 - SP - Primeira Turma p Rel. Min. Sydney Sanches, in RTJ 148/490).

Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional (CP, artigo 59, III).

Aliás, não é lícito dar de mão à circunstância de que a lei presume a periculosidade do "condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa", haja vista que subordina a concessão de livramento condicional a exame criminológico elidente, ou, por outras palavras, atestatório da cessação da potencialidade recidivista (CP, parágrafo único do art. 83).

A orientação desta Câmara inspira-se na enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 65.501-SP, verbis;

"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias". (cf. R.T.J. 123/457)

"O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário" (Habeas Corpus nº 74.301-3, de São Paulo, DJU 6.12.96, pág. 48.711).

Acresce ponderar que a concessão de regime semi-aberto ao autor de roubo desvitaliza a eficácia intimidante da pena, significando dizer que incentiva subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência a pessoa..

Anote-se, por último, que, a prevalecer o entendimento pelo qual a determinação do regime prisional é corolário imperativo da quantidade da pena reclusiva aplicada, seria obrigatório, em linha de coerência, aquinhoar o autor de roubo simples com o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, "c"). A impropriedade, inconveniência e injustiça de tal posição saltam aos olhos.

Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do código Penal, força é convir que o agente de roubo sujeita-se ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em evidência "personalidade" marcadamente defeituosa (cf., exemplificativamente, ac.

un. na ap. nº 673.255/1 de São Paulo).

Afinal, "o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo"(JUTACRIM 88/870. Este regime é, portanto, o único compatível com esse tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seu autor.

Sem embargo, não falta que, escudado no pretexto da inadequação do sistema carcerário, entenda compatível com o interesse público a manutenção de assaltante em regime aberto, sob a forma domiciliar.

Ora, tangencia a mais cândida ingenuidade supor que perigoso assaltante irá observar escrupulosamente as regras do regime aberto, muito especialmente as relativas ao recolhimento "durante o período noturno e nos dias de folga"...

Conceder regime aberto (e até mesmo o intermediário) a autor de roubo não significa apenas abrir uma porta para a impunidade, mas, em verdade, rasgar a via larga da reincidência. Provam-no as alarmantes estatísticas sobre fugas dos institutos penais agrícolas e sobre a execução de crimes por supostos reclusos em tal sistema. Em poucas palavras: regime outro que não o fechado para assaltante é crime de lesa-sociedade. Regime aberto para rapinante tem o odor, o sabor e a cor de escandalosa impunidade." (os grifos constam do original) (Apelação nº 1.083.043/1, de Americana)

Em julgado, também de recurso contra decisão proferida por este juízo, assim decidiu a 5ª Câmara da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"...o regime inicial fechado para desconto da corporal deve ser mantido, pois a infração penal praticada com emprego de arma e concurso de agentes, revela temibilidade e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade dos agentes, a justificar início de regime mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência dos artigos 33, § 3º c.c. art. 59, ambos do Código Penal). (Apelação Criminal nº 00485355.3/1-0000-000, Relator, Desembargador Marcos Zanuzzi, 21 de setembro de 2006).

Ainda, não podem apelar em liberdade, porquanto a gravidade do crime, e o modus operandi devem influenciar na concessão da liberdade para recorrer, e em se tratando de roubo praticado mediante grave ameaça, com concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, salvo prova excepcional em contrário, a regra é a prisão provisória do réu.

Assim é o entendimento de jurisprudência, conforme o V. Acórdão que segue, brilhantemente relatado pelo eminente Magistrado Haroldo Pinto da Luz Sobrinho: "O conceito amplo de bons antecedentes, como requisito da liberdade para apelar, compreende, além dos episódios da vida pretérita do réu, as circunstâncias em que praticou o delito tratado na sentença cujo reexame pretende em grau de apelação" (HC - 218.978/1 - TACRIM_SP - 2ª Câmara - Rel. Haroldo Luz - RJDTACRIM 13/196)

E, ainda:

Habeas Corpus - Condenação por roubo majorado - Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência - Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal - Situação fática inalterada - Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau, ademais, não ofende a garantia

constitucional da presunção de inocência. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2218120-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. 2. O Juiz sentenciante, conforme o art. 387, § 1º, do CPP, ao concluir pela necessidade da decretação da custódia cautelar ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do delito - roubo praticado com arma de fogo e concurso de agentes, em um restaurante - e pelas condições pessoais desfavoráveis do réu, decidiu conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior. Ficou consignado, ainda, que o réu possui condenações penais anteriores por crimes patrimoniais, o que denota sua reiteração delitativa. 3. (...). 4. Ordem denegada. (HC 497.109/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)

Ademais, os réus encontram-se presos por força de prisão preventiva, e segundo a melhor doutrina, e jurisprudência majoritária, o dispositivo é inaplicável no caso de réu preso provisoriamente.

Segundo o ilustre penalista Damásio Evangelista de Jesus:

"Segundo o entendimento pacífico do STF, essa disposição é inaplicável a réu preso em razão de flagrante ou preventiva, uma vez que e/a visa apenas abrandar o princípio da necessidade de e/e recolher-se à prisão para apelar (RHC 54.430, DJU 26.11.76, p. 10203). Assim, réu que por ocasião de sentença condenatória se encontrava preso em razão de flagrante ou preventiva, embora primário e de bons antecedentes, não pode apelar em liberdade (RHC 55.109, DJU 27.5.77, p. 3459, RHC 56.953, DJU 27.4.79, p. 3381; RHC 58.286, DJU 3.10.80, p. 7735). Sobre o assunto, decidiu o TJSP que "Lei n. 5.941, de 1973, é de interpretação restrita. Não nulificou a prisão em flagrante delito, cuja permanência no sistema processual vigente, vai até a sentença. Se esta for absolutória, o réu será posto em liberdade. Se for condenatória, aquela permanência se prolonga, porque um dos seus efeitos (art. 393, I) é ser o condenado conservado na prisão. Se for de pronúncia, só então o magistrado deverá reexaminar a custódia provisória, para revogá-la caso satisfaça o agente os requisitos legais", (RT- 500/318). No mesmo sentido: RT 531/295 e RTJ 88/69; RHC 57.947, DJU 13.6.80, p. 4461, e RHC 58.053, DJU 12.8.80, p. 5786. E, se a acusação apela visando à agravação da reprimenda, o réu permanece detido, ainda que já tenha cumprido o quantum da pena imposta na sentença condenatória (Código de Processo Penal Anotado - Direito Informatizado Saraiva - 1ª Edição em CD-ROM - 1995).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"É que o paciente respondeu o processo preso cautelarmente, durante toda a instrução, hipótese em que, sobrevindo sentença condenatória, não há de permitir-se que apele solto, ainda que possua os atributos elencados pelo ilustre impetrante. Neste sentido, aliás, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui

um dos efeitos da respectiva condenação. 2. Na espécie, o réu, preso em flagrante, permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não caracterizando constrangimento ilegal a preservação da sua custódia pela sentença condenatória, mormente porque permanecem hígidos os motivos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. As condições pessoais favoráveis não são requisitos bastantes para a concessão de liberdade provisória, e, ademais, no caso dos autos, o paciente não logrou demonstrar ocupação lícita e possuir residência no distrito da culpa. 4. Habeas corpus denegado." (HC nº 207.906/RJ, Quinta Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.02.2012).

E, no caso sub judice persistem os requisitos para a manutenção da custódia do paciente, pois os delitos apurados roubo duplamente qualificado e associação criminosa armada demonstram a periculosidade do agente e a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicabilidade da lei penal. Sendo assim, não pode ser concedido ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade". (AC 2018.0000350330, Habeas Corpus nº 2062136-72.2018.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. França Carvalho, 10 de maio de 2018.)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu GIOVANI APARECIDO DA ROSA VICENTIN à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa; e o réu GILVOMAR DUARTE à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, ambos no regime inicial fechado, e com o dia-multa fixado no piso, como incursos no artigo 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal; bem como para condená-los no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram.
P. I. C.

Americana, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA